

1500412-41.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... com relação ao réu Matheus quanto ao tráfico e a associação para o tráfico; a pena deve ser majorada pela quantia relevante de droga encontrada na casa de Caio e natureza diversa; incide a agravante do crime cometido no período de pandemia e há relação direta com o tráfico; não é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pela grande quantia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500412-41.2022.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500412-41.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2046520/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 23090379 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2046520 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO ARRUDA MICHELLIS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Caio Arruda Michellis e Matheus Augusto Chadi, qualificados nos autos, por terem, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33 e 35, "caput" da Lei nº 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 311, caput, do Código Penal, os dois últimos com relação a Caio. Segundo apurado, em data incerta, antes de 17 de fevereiro de 2022, Matheus e Caio associaram-se para praticar o narcotráfico na modalidade delivery; guardavam na residência de Caio grande quantidade de maconha e haxixe, para entrega a consumo de terceiros; policiais da DISE receberam informações de que Matheus estaria comercializando drogas, auxiliado por Caio; após

campana e constataram que no período noturno havia grande movimentação de pessoas na casa de Matheus, local frequentado por Caio; em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na residência de Caio encontraram 2 balanças de precisão, várias embalagens para acondicionamento de droga, um bloco de anotações, R\$ 441,00, celular, 6 munições soltas, 213,39g de maconha e 6,83g de haxixe; lá foi apreendido o veículo sobre o qual recaíam notícias de sua utilização para entrega de drogas e que estava com a numeração de chassi suprimida e placa sem tarjeta e lacre; o laudo pericial constatou a eficácia de tais munições; na casa de Matheus apreenderam seu telefone celular, posteriormente periciado e nele encontrados elementos que atestam seu envolvimento com o tráfico.

A denúncia foi recebida em 27/04/2022 (fls.251/257)

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls.345/349).

Em audiência realizada em 27/06/2022 foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus (fls.447/450).

Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a procedência parcial, com a condenação de Caio pelo tráfico de drogas pela posse de munição. Sustentou que: os policiais falaram que fizeram campana na casa de Matheus e identificaram movimentação típica de tráfico de drogas; durante o cumprimento do mandado encontraram drogas, munições e petrechos na casa de Caio; a prova extraída do celular de Caio indica que ele fazia venda e movimentava quantia relevante de droga; a versão de que a droga era destinada ao consumo não convence; ficou comprovada a ocorrência da posse irregular da munição de arma de fogo; não é cabível a inversão do ônus da prova com relação ao crime de adulteração de veículo e pela falta de prova de autoria e deve ser absolvido; a prova é precária com relação ao réu Matheus quanto ao tráfico e a associação para o tráfico; a pena deve ser majorada pela quantia relevante de droga encontrada na casa de Caio e natureza diversa; incide a agravante do crime cometido no período de pandemia e há relação direta com o tráfico; não é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pela grande quantia de droga traficada e para o STJ é possível considerar essa circunstância nas duas etapas da dosimetria e é possível extrair do laudo uma série de mensagens em vários dias indicando que ele movimentava drogas com diversas pessoas e não é traficante eventual; é incompatível a substituição por penas restritivas de direito e não recomendável; deve ser fixado o regime inicial fechado; deve ser mantida a prisão preventiva do Caio.

Em alegações finais a doughta Defesa do réu Caio pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a absolvição do réu pelos demais crimes. Sustentou que o réu confessou que é usuário e trafica para sustentar seu próprio vício; deve ser absolvido do crime de posse de munições por atipicidade; não há potencialidade lesiva; não foi apreendida arma de fogo compatível com a munição; deve ser reconhecido o tráfico privilegiado com redução máxima da pena; a quantidade de drogas apreendidas não é elevada e não pode obstar o benefício; é primário, não se dedica a atividades ilícitas e não integra organização criminosa; deve ser absolvido dos delitos de associação para o tráfico, não existe prova de vínculo associativo estável e permanente entre ele e Mateus; em caso de condenação por tráfico deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.462/535).

A doughta Defesa do réu Matheus pediu a absolvição dele. Arguiu que não foi encontrado nada de ilícito na posse dele no dia da busca e apreensão; a própria acusação afirma que as provas são fracas e pede a absolvição de Matheus; a versão dos policiais é duvidosa, afirmaram que nada de ilícito foi encontrado com o réu e que nunca o viram entregar nada para outra pessoa; não houve nenhuma abordagem dos possíveis compradores na residência do acusado; a única prova contra ele é o conteúdo do seu celular, porém nenhuma conversa demonstra que estava associado a Caio; o corréu afirmou ser o único dono das drogas e que Matheus não tem envolvimento com o ilícito; as testemunhas de Defesa afirmaram que nunca ouviram falar do envolvimento do réu com crimes; ficou comprovado pela oitiva das testemunhas que as movimentações em sua casa são de clientes de sua mãe, cabeleireira, e de amigos que iam jogar vídeo game; o réu passou o contato de de

Caio para “Mah Silva” porque sabia que ele era usuário e poderia ter para vender a ela. Pediu a absolvição por ausência de provas de que concorreu para a prática dos crimes ou por falta de provas. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de redução; o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com afastamento da pena de multa por ser pessoa pobre (fls.542/558).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo foi devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (fls.10/02), boletim de ocorrência (fls.75/76), auto de exibição e apreensão da droga (fl.19), auto de constatação provisória de droga (fls.70/72), laudo de exame químico de entorpecente (160/162), laudo pericial das munições (fls.168/170) e exame metalográfico (fls.439/446).

Consta no laudo toxicológico que foram periciados fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, e porção de substância com aspecto resinoso de coloração amarronzada e de morfologia irregular, cujos resultados foram positivos para Tetrahydrocannabinol, substância indicada em lista proibitiva no Brasil.

Consta no outro laudo que os cartuchos de calibre .38 SPL apresentaram-se eficazes, enquanto os cartuchos de calibre .21 SWL apresentaram falha nos testes. Por fim, o exame metalográfico concluiu que a numeração do chassi estava parcialmente suprimida, com vestígios de abrasão. A autoria também é certa e atribuída ao réu Caio, em relação aos crimes de tráfico e posse ilegal de munições, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório Caio confessou em parte. Afirmou que a droga apreendida era sua, para sustentar seu vício as vender para seu ciclo de amigos. Relatou que quando a avó morreu aumentou o vício para fugir da realidade e vendeu pertences como videogame e bicicleta. Mencionou que fumava maconha, usou cocaína duas vezes e para parar aumentou mais o uso, misturava o haxixe na maconha, começou aos 18 anos. Declarou que na maconha pagou R\$ 550 e no haxixe pagava 20g por droga. Salientou que todo mês seu pai lhe pagava R\$ 700, era a avó quem sustentava a casa, depois que faleceu sua mãe trabalhava e pediu ajuda ao pai. Frisou que fazia 4 dias que o pai tinha depositado mais dinheiro, pois falou que a moto tinha quebrado. Narrou que essa munição era de seu avô, ele era gerente do banco e no fundo de sua casa achou no escritório antigo dele. Declarou que essas munições estavam enferrujadas, desde crianças estas armas ficavam espalhadas pela casa, a arma nunca viu. Disse que as munições ficaram espalhadas no seu quarto e não tinha uso. Falou que comprou a moto num site de vendas, é uma 125, na tabela custa R\$ 4 mil ou R\$ 5 mil, o vendedor disse que venderia abaixo do preço de tabela. Contou que o rapaz falou que não tinha como ter transferência, mas passou documentos em branco e vendeu abaixo do preço de tabela, R\$ 2800,00 a R\$ 3.000,00. Negou ter adulterado o chassi.

Comentou que sua moto foi roubada e isso foi registrado na câmera de segurança, conseguiu as filmagens e postou no Facebook, no dia seguinte a achou jogada num terreno, encontrou o chassi raspado e o lacre violado. Afirmou que foi no Poupatempo para remarcar e disseram que somente a dona poderia requerer e fazer o boletim de ocorrência. Relatou que é amigo de infância de Matheus, já estudaram juntos e fumavam maconha. Negou conhecer “Ma Silva”, sabe que Matheus tinha relacionamento com ela e era usuária. Declarou que só fornecia para amigos com quem fumava junto, como Matheus, Gabriel, Eduardo, Antônio. Contou que já trabalhou com Matheus Bueno, trabalhou com ele na concessionária, o Guilherme Romeu é filho do dono do espetinho e trabalhou como entregador, são de seu ciclo de amizade. Narrou que mais fumava com eles, mas tinha vezes que queriam sair sozinhos e pediam para vender dez, às vezes dava maconha para eles por serem próximos. Esclareceu que tinha essas balanças para pesar as drogas que comprava dos traficantes. Salientou que uma vez já reclamou de traficante que lhe vendeu droga a menos e ele o mandou

ir comprar com outro. Confirmou que é viciado em drogas, desde o primeiro dia da prisão sentiu crise de abstinência e não se alimentava, vomitava, chamaram a psicóloga e ela lhe receitou calmante, depois a mãe lhe entregou cigarro e fumo de corda. Negou ser associado ao Matheus, ele era usuário. Ressaltou que frequentava a casa de Matheus, a mãe dele era cabelereira e tinha muitas clientes mulheres lá, o réu frequentava sua casa. Acrescentou que Matheus sofreu acidente e ele fazia bicos numa adega. Negou que o réu Matheus tenha intermediado alguma venda ao depoente, ele é usuário e falou aos policiais que ele não tinha nada a ver. Negou ter sido condenado e nem ter passado pela Febem. Esclareceu que trabalhou por cinco meses num lava rápido e fazia bico no Chopp Center, ganhava R\$ 350.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparado em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal, "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem compatibilidade ou concordância". Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas.

O réu Matheus negou o crime. Negou vender drogas ao Caio, nunca fez nada de ilícito. Afirmou que estava se relacionando com "Ma Silva", ela queria comprar, passou o número do Caio para ele indicar alguém, não sabia que ele vendia, mas que era usuário. Mencionou que é trabalhador e tem três filhos. Narrou que sua casa é pequena, paga com o auxílio-doença e mora com a mãe, três irmãos e o pai frequenta, seus amigos Marco Aurélio e Caio passavam lá, nunca para mexer com drogas. Negou ter passagem. Negou sair de casa e ficar numa vila escura. Negou ter indicado outra pessoa ao Caio para ele vender drogas. Disse que às vezes fumava maconha com o corréu, o Caio fumava muita maconha. Ressaltou que sua mãe falou que o Caio estava viciado, ele fumava toda hora, por isso passou o número para menina. Acrescentou que o réu Caio falava que não queria mais viver. Falou receber benefício de R\$ 1800 a R\$ 2 mil de INSS e sustenta a casa.

A testemunha Marcelo afirmou que obteve informações de que os réus vendiam entorpecentes e representou por buscas. Relatou que na casa de Matheus nada de ilícito acharam, na casa de Caio acharam bastante maconha, haxixe e embalagens de drogas, anotações, balanças de precisão, munições de armas, em pontos diferentes do quarto dele. Mencionou que no quarto da mãe de Caio acharam arma de fogo. Declarou que Caio falou que comercializava drogas a amigos. Frisou que tinha informações de que ele vendia por meio do delivery. Narrou que o policial Rocha constatou pela análise dos aparelhos que os dois réus traficavam juntos. Informou que fizeram diligências prévias, na casa de Matheus constataram movimentação de pessoas no período noturno, viram que Caio frequentava a casa e receberam as informações de que trabalharam juntos. Negou se lembrar se fizeram campana na casa de Caio.

Confirmou que fez relatório da campana na casa de Matheus. Contou que Matheus negou a participação. Negou precisar o horário exato das campanas. Negou ter abordado os frequentadores. Negou ter visto Matheus entregando alguma coisa para estas pessoas. Negou saber se na casa havia salão de cabelereiro. Disse que algumas vezes o réu ficava numa viela. Negou ter visto se Matheus tinha objeto na mão. Negou que Caio fosse conhecido no meio policial. Afirmou que por ter informações que Caio fazia entrega via delivery apreenderam a moto e lá constataram que a moto tinha sinais adulterados, não falou com o réu sobre isso. Negou se lembrar o que o réu disse sobre a munição, a arma no quarto da mãe ele disse ser do avô e a mãe confirmou. Informou que apreenderam 400 e poucos reais, ele disse ser da pensão do pai.

A testemunha Marcelo Rocha afirmou que participou da busca e apreensão da casa dos réus. Confirmou a apreensão de drogas no quarto de Caio, as balanças de precisão e munições calibre 38 e 32, no quarto de Caio. Relatou que a mãe falou sobre a arma de fogo e disse que o filho não sabia. Mencionou que a moto estava com chassi raspado e faltava o lacre. Declarou que fez laudo técnico dos celulares dos réus e com certeza os dois estão ligados ao tráfico. Falou que numa conversa do celular de Matheus uma usuária solicita compra de maconha, ele informa que tem um amigo e vai indicar a ela, esse amigo é o Caio. Esclareceu que o réu entrou em contato com o

Caio. Disse que no celular de Caio há essa mesma conversa de venda de entorpecentes e outras. Narrou que Caio disse que a droga era dele e não vendia e era usuário. Frisou que acharam 441 reais na carteira de Caio e ele alegou ser dado pelo pai. Falou que nas conversas o Matheus chamava o Caio de "Gordão". Informou que pela conversar "Ma Silva" é de Cândido Mota e viria a Assis comprar droga, Matheus disse que vendia por grama e por quilo e indicou o Caio, combinaram de se encontrar perto da chácara Bela Vista. Afirmou que Matheus estaria guardando a droga, depois quando ele começou a trabalhar numa adega essa droga voltou para o Caio. Relatou que numa das mensagens negociavam haxixe. Mencionou que Matheus indicava clientes para o Caio vender entorpecentes. Negou conhecer o Caio. Declarou que durante as buscas várias vezes Caio disse ser usuário. Negou que ele tenha comentado que vendia ou dividida com amigos. Negou ter constatado outro cliente relativo aos dois além de "Ma Silva". Frisou que verificou o celular após a autorização judicial. Comentou que numa outra conversa Matheus queria uma droga e Caio falou que levaria para ele usar. Ressaltou que Matheus não foi preso no dia da busca porque nada de ilícito acharam na casa. Negou saber se na residência do Matheus há salão de cabelereiro. A testemunha Dulcinéia afirmou que conhece Caio desde que nasceu, é amiga da mãe dele desde 1989. Relatou que foi uma surpresa o que ocorreu. Negou saber de envolvimento com drogas. Mencionou que ele fazia "bicos" como lavador de carro. Declarou que é bom menino e não ouviu comentários que é usuário de drogas. Negou conhecer o réu Matheus.

O informante Ulysses negou saber da acusação do tráfico. Afirmou que o réu fazia "bicos", já trabalhou num lava rápido, na época estava desempregado. Relatou que soube que a moto era do réu porque ele disse que comprou há alguns meses. Mencionou que após o falecimento da mãe do depoente fazia umas visitas na casa e sentia cheiro, a irmã falou que Caio usava drogas. Disse que Caio era muito dócil e nunca se envolveu em brigas. Falou que o pai do réu o auxiliava a pagar contas. Frisou saber que Matheus era amigo do Caio, em alguma visita o viu na casa.

A testemunha Simone negou saber se Matheus usa drogas. Relatou que ele trabalhava no sítio do sogro, acidentou e recebia dinheiro do INSS. Negou saber de fato que desabone a conduta dele. Mencionou que é amiga do pai do réu e conhece Matheus desde pequeno. Falou que frequenta a casa do réu, a mãe dele é cabelereira na própria casa e frequenta o local uma vez por semana, há clientes na casa. Frisou que o réu tem três filhos e cuida deles.

A testemunha Marco Aurélio afirmou que conhece Matheus há muito tempo e ele não mexe com estas coisas. Relatou que ia na casa do réu e ficava a madrugada toda, nunca aconteceu nada. Mencionou que o réu e dois amigos frequentavam a casa a noite. Declarou que as dez da noite saía do trabalho e ia na casa do réu conversar. Salientou que a mãe do réu era cabelereira e tinha um salão na residência. Disse que durante a semana ia todos os dias na casa de Matheus. Negou ter visto pessoas frequentando a casa como ponto de venda de drogas. Frisou que o réu tinha outros irmãos na casa. Negou que ele saísse de casa e ficasse na frente, tinham o costume de ficar na área. Narrou que durante o dia Matheus ficava na casa dele, andava de skate e voltava, mas não presenciava porque estava no trabalho. Ressaltou que o réu sofreu um acidente e um braço dele não funciona. Negou conhecer o Caio e não o via na casa do réu.

Pois bem. Para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido basta a ocorrência de uma das condutas previstas no artigo 12, da Lei 10.826/03 (possuir ou manter arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Não se exige, para a tipificação, a exposição de outrem a risco. Isso, porque se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade pública. Não impede a tipificação a apreensão isolada de munições, pois "carregar tanto a arma quanto a munição, mesmo que separadamente, é delito" (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª Ed., São Paulo, RT, 2009, p.87).

A finalidade da lei é evitar que aquele que a portar possa utilizá-la indevidamente, preocupando-se o legislador com o risco que as armas representam para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade

física, entre outros. Assim, até mesmo como forma de prevenção, tal conduta é punível antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto, conforme entende a jurisprudência.

Portanto, é suficiente que o agente tenha em sua posse munição, sem licença da autoridade competente, com dolo consistente na vontade livre e consciente de realizar tal conduta, bem como que, pela sua comprovada eficiência, possa produzir resultado lesivo efetivo.

No caso concreto as munições de calibre .32 foram submetidas a teste e o expert constatou que existe falha. Por outro lado, atestou que as duas munições de calibre .38 apresentaram-se eficazes para os fins a que se propõe (fl.169).

Assim, excluindo as munições ineficazes e partindo da premissa de que o réu está sendo acusado da posse de duas munições calibre .38 desacompanhadas de arma de fogo, eis que a arma de fogo pertencente à genitora tinha o calibre .32, tanto a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto a do e. Supremo Tribunal Federal mudaram sua orientação para reconhecer a atipicidade da conduta em situações como esta. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.

IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, não é admissível a inovação de teses recursais apenas no agravo regimental interpostos contra decisão proferida no recurso especial. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. 1. A decisão da Corte estadual, no sentido de afastar a incidência do princípio da insignificância e anular a sentença absolutória, limitou-se à análise do pedido expressamente formulado pelo Parquet em suas razões recursais. 2. O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso (HC 209.266/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17.03.2016, DJe 31.03.2016).

PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. USO RESTRITO. DESACOMPANHADA DO ARMAMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, apesar da posse ilegal de munição configurar crime de mera conduta e de perigo abstrato, nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de projéteis desacompanhados de armamento capaz de deflagrá-los, é cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, haja vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Precedentes. 2. No caso concreto, denunciado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, o agravante foi absolvido sumariamente pelo juízo de primeiro grau, que entendeu sem tipicidade material a conduta de possuir e manter sob a guarda, no interior do imóvel onde reside, apenas 8 (oito) munições de uso restrito, sem a arma de fogo necessária para deflagrá-las. 3. Ao acolher o recurso em sentido estrito do Ministério Público para afastar a incidência do princípio da insignificância e a absolvição sumária, restabelecendo o curso da ação penal, o Tribunal de origem dissentiu do entendimento sedimentado pelos tribunais superiores acerca do tema. 4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de restabelecer a absolvição sumária expedida pelo Juízo de primeiro grau. (AgRg no Recurso Especial nº 1.647.947/SP, 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019, destaquei).

Dessa forma, em atenção ao precedente das Cortes Superiores ressalvo meu entendimento e acolho a absolvição do acusado Caio ante a insignificância da conduta.

Passo a analisar o tráfico de drogas, que se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto

alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal.

Segundo o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos chegaram informações na DISE alegando que Matheus estaria comercializando e guardando drogas em sua residência e que referido crime vinha acontecendo há semanas. Em trabalho de campo a polícia constatou movimentação de pessoas no local durante a noite, típico de ponto de venda de drogas, inclusive Matheus saía de sua casa e ficava em uma rua estreita, próximo a sua residência (fls.13/14). Durante os trabalhos, noticiaram que Matheus estaria tendo ajuda de “Caio Gordão” para a guarda de entorpecentes. Durante campanhas os policiais constataram que Caio frequentava a casa de Matheus (fl.16).

Realizada diligência de busca e apreensão, na casa de Matheus nada de ilícito foi encontrado. Na casa de Caio localizaram em seu quarto duas balanças de precisão; diversas embalagens utilizadas para acondicionar drogas; um bloco de anotações; R\$ 441,00 em dinheiro; seu telefone celular; munições soltas de calibres 38 e 32; além de maconha e haxixe, divididas em diversas porções (total de 213,39g de maconha e 6,83g de haxixe). Os policiais apreenderam também o motociclo dele, o qual tinha o número de chassi suprimido e a placa sem a tarjeta e o lacre.

Ficou claro nos autos que Caio praticava o tráfico de drogas. Primeiro porque ele confessou, mesmo alegando ser usuário e adquirir grandes quantias para durar todo o mês, que vendia os entorpecentes para pessoas mais próximas. Ademais, a forma como se deu a apreensão indica a traficância. Na casa de Caio também foram apreendidas duas balanças de precisão e muitas embalagens utilizadas para o preparo das porções de drogas, petrechos típicos do comércio espúrio. Não é crível que Caio utilizasse a balança de precisão para pesar drogas para seu consumo, pois se viesse a menos certamente não iria discutir com o traficante.

Por fim, as mensagens encontradas no celular do corréu Matheus deixam claro que Caio vendia drogas e não apenas para pessoas próximas. Isso porque em conversa com contato salvo como “Mah Silva”, esta queria comprar drogas e Matheus indicou o amigo Caio como fornecedor de maconha, mandou mensagem para ele afirmando que “Mah” iria entrar em contato com ele para adquirir drogas e o réu manifestou consentimento, mesmo sem sequer conhecê-la.

Além disso, a quantidade de petrechos utilizados para embalo de drogas encontrada no quarto do autuado, como se pode observar a fl.34 (3 rolos de plástico film e inúmeras embalagens tipo ziplock) não permite concluir que ele é só usuário e vendia apenas pequenas quantidades para seus amigos. A condenação de Caio pelo crime de tráfico de drogas se impõe.

Por outro lado, no tocante ao réu Matheus, não há que falar em coautoria do crime de tráfico de drogas, ao menos em relação ao crime em tela. Com efeito, no aparelho celular do acusado foram encontradas mensagens comprometedoras, indicando que pode ter traficado.

Em 18/01/2022 Matheus conversou com interlocutor não identificado e comentaram sobre a prisão de alguém conhecido. Interlocutor disse que a pessoa que havia sido presa tinha saído da casa dele com “2 quilos”, mas que não sabia se ele já tinha “soltado”. Durante o diálogo Matheus contou que no dia anterior ficou o dia inteiro com esse preso “nas entrega” (sic) e se fosse um dia depois teria sido preso junto. Afirmou ao interlocutor: “vou deixar o mano passar batido não tio o cara é meu parceiro vou ver se consigo dar uma fortalecida mano pelo menos uma vez no mês aí o cara é meu parceiro cê é loco” (sic).

No dia 13/02/2022, contato salvo no celular do denunciado como “Mah Silva” indaga Matheus onde poderia encontrar maconha para vender, pois seu amigo queria comprar

"20 conto" (sic), Matheus disse à amiga que ele só vendia "de grama ou kilo", ela pergunta se tem que buscar ou se "faz delivery". Matheus conversa com Caio informando-o sobre a venda, Caio diz "pra ela dar um salve" (sic) e Matheus passa o contato de "Gordão" (Caio) para a amiga.

Não obstante, no momento das buscas na residência de Matheus nada de ilícito foi encontrado. Embora as denúncias que deflagraram a presente ação penal indicassem que Caio o auxiliava e guardava drogas, tal fato não foi confirmado durante a persecução penal. Nenhuma prova ligou ao Matheus os entorpecentes apreendidos na residência do corréu. Caio confessou que toda a droga apreendida era dele, o que está em consonância com as demais provas.

No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a possibilidade acerca do delito e da autoria. "É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP" (In RT, v. 809/657).

Como se anotou, "Uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo" (TJMG, APCR 000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

Outrossim, foi achada a quantia de R\$ 411,00 na posse do réu Caio e ele não comprovou a origem lícita. Assim, deve ser decretado o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, do CP c.c art. 63 da Lei n.º 11.343/06. Nesse mesmo sentido, cite-se o seguinte julgado:

Inexistindo a prova da origem lícita e havendo presunção de que os bens pretendidos eram produto da prática do tráfico, não há falar em restituição, apresentando-se correta a decretação de perdimento dos bens em favor da União, na forma delimitada pelo art. 60 e § 1º, c/c art. 63 da Lei nº 11.343/06 (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0040.08.072861-7/001(1), 4ª Câmara Criminal, Rel. Walter Pinto da Rocha. j. 28.01.2009, unânime, Publ. 11.02.2009, destaquei).

Quanto ao crime de associação para o tráfico, tem-se que este não se confunde com o simples concurso de agentes, sendo necessário mais elemento para condenação. Nesse sentido, colaciono aos autos julgados do E. Tribunal de Justiça Paulista:

O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para a sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado (TJSP, Apelação 295.901-3/1-00, 6ª Câmara Criminal, rel. Des. Barbosa Pereira, j. 06.04.2000, RT 779/571, destaquei).

Não configura o delito a convergência ocasional de vontades e eventual colaboração entre algumas pessoas para o êxito da delinquência mercantil (TJSP, RSE 250.744-3, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Canguçu de Almeida, j. 27.04.1998, JTJ 209/284, destaquei).

No caso em tela, embora a prova documental, consistente nas mensagens encontradas no aparelho celular de Matheus indiquem que ele encaminhou uma compradora para o corréu Caio, não há prova segura do ânimo de associação com caráter duradouro e estável para a prática do tráfico entre eles. No Direito Processual Penal as provas são relativas, de forma que o juiz deve analisá-las em conjunto. E no caso concreto os indícios resultaram isolados.

Assim, Caio e Matheus devem ser absolvidos do crime de associação para a prática do crime de tráfico de drogas em nome do princípio do in dubio pro reo, eis que os indícios existentes contra eles são insuficientes para ensejar uma condenação

criminal.

Pelo mesmo motivo, inclusive, é o caso de se absolver Caio da acusação do outro crime. O artigo 311, do Código Penal, que trata do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tipifica as condutas de “adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.

Adulterar significa modificar, em caráter permanente, inscrição já existente, e remarcar tem o sentido de inserir nova sequência sobre inscrição anterior, com compleição igualmente definitiva. No caso em tela a adulteração restou demonstrada pelo exame metalográfico que constatou numeração do chassi parcialmente suprimida, com vestígios de abrasão (fls.439/446).

Todavia, não há prova concreta de que foi Caio quem praticou tal fato, de sorte que a indicação da autoria não é segura no tocante à adulteração, impondo-se a declaração do non liquet. Além disso, não há certeza acerca de quando teria ocorrido o crime e nem se quando o réu adquiriu a moto ela estava com o chassi adulterado. Ele mesmo afirmou que o vendedor alegou que não seria possível realizar a transferência, o que é indício de prévia adulteração.

Destarte, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu Caio nos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições é medida que se impõe.

Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas de Caio, eis que não milita em favor do réu qualquer dirimente: Consoante a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena (STF, HC 127241/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado 04-08-2015, STF, RHC 117489/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado 18-06-2013) e constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STF, RHC 122598, Rel. Min. Teori Zavaski, julgado em 14-10-14). A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevadíssima intensidade pela variedade e pela grande quantidade de droga apreendida (213g de maconha, além de 6g de haxixe). A grande quantidade e a variedade do entorpecente apreendido revelam o dolo exacerbado a exigir certo incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, possibilitando a circunstância ao agente atingir maior número de usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias. É primário e não ostenta maus antecedentes. Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo. Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em: a) 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase deve ser reconhecida a atenuante da confissão, pois o réu confessou o crime em Juízo e, embora tenha feito para tentar atenuar sua culpabilidade, tal fato foi levado em conta na formação da convicção, razão pela qual é justo que sirva para atenuar sua pena. Reconheço a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, pois o isolamento e as restrições impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Também há notícias de que policiais tem ficado doentes por causa do Coronavírus, de modo que não é absurdo concluir que essa pandemia pode afetar a fiscalização de crimes como o tráfico. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. STJ:

“(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art.

61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública" (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei).

Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Compenso uma pela outra e mantenho as penas no mesmo patamar.

Na terceira fase não há causas de diminuição de pena. Nada obstante a primariedade, a expressiva quantidade de entorpecente guardada (213g de maconha e 6g de haxixe) e o fato de ter balanças de precisão e vários petrechos relacionados ao tráfico, torna inaplicável a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque demonstrou que não era traficante ocasional. Ninguém começa traficando esta quantia de droga, inferindo-se destas circunstâncias que o réu já vinha se dedicando às atividades delituosas há muito tempo.

Na esteira do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, "a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa, ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena" (REsp nº 1.021.782, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22-3-2010).

Nesse sentido é outro julgado do STJ:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELO EM LIBERDADE. ART. 44 DA LEI 11.343/07. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. [...] III. A redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 aplica-se aos delitos definidos no caput do referido dispositivo legal, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique ao crime ou integre organização criminosa. IV. O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na hipótese dos autos, levando em consideração a quantidade de droga apreendida, bem como o indicativo de participação do paciente em organização criminosa. V. Ordem denegada. (HC nº 194.483/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 28-4-2011 (destaquei)).

Aliás, importante frisar, como feito na fundamentação do aresto citado, que "a mens legis da causa de diminuição de pena é alcançar pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente com alto poder destrutivo" (HC 194.454, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 11/04/2011).

Ressalto que recentemente a jurisprudência do STJ já admitiu a possibilidade de a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes serem considerados tanto para aumentar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas, quanto para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11343/06, na terceira etapa da dosagem da pena. O acórdão foi redigido dessa maneira:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 578.782 – SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j.04/08/2020, destaquei).

A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal já admitiu essa possibilidade, conforme julgado adiante citado:

Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas: 3,410 quilos de maconha) à pena de 5 anos de reclusão, regime inicial fechado com base na hediondez já afastada por ocasião da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. 4. Irresignação persistente quanto a não aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria da pena que se afasta. 5. Jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e a conclusão, com base no contexto dos fatos, de que o paciente se dedica a atividades criminosas, dada a quantidade de droga apreendida. 6. Determinação para que o juízo da execução, afastando a hediondez, fixe de forma fundamentada o novo regime de cumprimento da pena ainda não realizada. 7. Antecipação indevida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. nos Emb. Decl. no Habeas Corpus nº 154462/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Gilmar Mendes. j. 30.11.2018, unânime, DJe 06.12.2018, destaquei).

Penso que é a hipótese dos autos. Embora o réu seja primário, infere-se que as circunstâncias do caso concreto levaram a crer que ele é criminoso habitual, evidenciando não ser merecedor da benesse. Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda aferida e do salário-mínimo vigente na época, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do CP.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi a relevante quantidade e variedade da droga traficada pelo acusado, do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico.

Justifico a fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena também pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal (montante da pena

e circunstâncias negativas), seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Carta Magna.

Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. Orig. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.09).

O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Nesse aspecto, acerca da necessidade do regime mais grave para o tráfico de drogas, cito o voto do eminente Desembargador Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0004588-12.2016.8.26.0189, julgado em 21/09/2017:

“Esse desgraçado vício da cocaína chegou em nosso país e, principalmente, nessa cidade de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem logradouros públicos, que foram praticamente tomados por viciados. É bom lembrar que o usuário de cocaína quando não tem dinheiro para adquirir a cocaína pura, que é em forma de pó, passa a se utilizar de uma forma inventada nos Estados Unidos, mais, precisamente na cidade de Nova York, no início dos anos 1970, denominada crack, aliás muito mais potente no sentido de fazer com que apenas com uma aspiração da fumaça tóxica (coloca-se a pedra em um pequeno cachimbo, conhecido como “marica”, geralmente de vidro, esquentada com uma chama de isqueiro ou fósforo, e a pessoa suga a fumaça que desprende da pedra de “crack”) já se torna dependente desta desgraça que foi inventada por indivíduos alheios a qualquer sentimento de piedade e que tinham somente interesse em ganhar dinheiro. Ora, uma pessoa que transforma seu semelhante num morto vivo, ou seja, um verdadeiro zumbi, como os que se vê na mídia, principalmente televisiva, indivíduos convivendo juntos na maior sujeira e promiscuidade, sendo que os locais onde essas pobres almas habitam, tem que ser constantemente lavado, com jatos de água e detergentes, pela Prefeitura Municipal, a fim de remover o fedor que exala do chão devido às secreções e excrementos que essas pessoas deixam naqueles locais. Tudo o que disse acima, e que é do conhecimento de todos, acontece por apenas uma razão, devido à ação de pessoas destituídas de qualquer sentimento de amor ao próximo, como é o caso do traficante e, nesses autos, do acusado. Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que, com sua atividade de traficantes, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas. O direito, como é cediço, é uma ciência mutável, ou seja, ele tem que acompanhar a evolução humana, e se adaptar às suas necessidades que mudam a cada época do desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, como uma das finalidades da pena é intimidar um possível criminoso, é mais do que óbvio que um crime como o tráfico de drogas, que, sem falar nos males causados à pessoa humana, abre as portas para inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, homicídios, prostituição etc.; não pode receber um tratamento menos gravoso do que um delito de menor potencial ofensivo. Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser preso não há outro regime, senão o inicial fechado, como forma de contraprestação do Estado à sua conduta. Fixar-se um regime mais benéfico do que o inicial fechado, seria conceder-se uma benesse ao réu, a qual ele não é merecedor”.

No mais, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou

reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade. Por fim, a Lei nº 12.736/2012 deu novas regras ao instituto da detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão